

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7123/2553

พนักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก
นายมานะน้อยหรือม่วย ประดิษฐ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), มาตรา 317

ป.วิ.อ. มาตรา 185, มาตรา 193, มาตรา 215, มาตรา 216, มาตรา 218, มาตรา
225

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจารตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 และฐานร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอมตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคสามและมาตรา 277 วรรคสาม แต่มีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยปราศจากเหตุอันสมควรตาม ป.อ. มาตรา 317 วรรคแรก จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 แก้วรรคของความผิดในบทมาตราดังกล่าวซึ่งมีระวางโทษต่างกันไม่มากนัก และเป็นการแก้ไขปรับบทให้ถูกต้องตามฟ้องโจทก์ แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จะแก้โทษด้วยก็เป็นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะลงโทษจำเลยที่ 2 ให้เหมาะสมตามความผิดได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และ 225

ความผิดฐานกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน อันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอมตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสาม ที่ใช้บังคับขณะจำเลยที่ 1 กระทำความผิด จะต้องมีส่วนร่วมกระทำชำเราเด็กหญิงอย่างน้อยสองคน โดยผลัดเปลี่ยนกันกระทำชำเราเด็กหญิงและโดยมีเจตนาร่วมกัน ในขณะที่กระทำความผิด ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายที่ 2 ไปบ้านที่เกิดเหตุและกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 2 พา ต. มาและจำเลยที่ 2 พาจำเลยที่ 1 ออกไปจากบ้านที่เกิดเหตุ หลังจากนั้น ต. กระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 และในเวลาใกล้เคียงต่อเนื่องกันยังมี ร. กระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 อีก พยานหลักฐานโจทก์ไม่ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ได้ร่วมคบคิดหรือนัดแนะกับคนอื่นในการกระทำความผิดอย่างไร ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 กระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 แล้วออกไปจากที่เกิดเหตุ จึงเป็นการกระทำโดยลำพังเฉพาะตัว ไม่มีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้าง และแก้ไขให้ถูกต้องได้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 277 วรรคแรกและวรรคสาม, 317 วรรคแรกและวรรคสาม

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยาน จำเลยทั้งสองขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม, 277 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 เป็นการกระทำ

ความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ขณะกระทำความผิดจำเลยที่ 1 มีอายุกว่าสิบเจ็ดปีแต่ยังไม่เกินยี่สิบปี เห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ประกอบมาตรา 53 ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจาร จำคุก 8 ปี และฐานร่วมกันกระทำความชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอมจำคุก 33 ปี 4 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ลงโทษฐานร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจาร จำคุก 12 ปี และฐานร่วมกันกระทำความชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม จำคุกตลอดชีวิต แต่พฤติการณ์การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสอง รวมทั้งให้การรับสารภาพกรณีมีเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้จำเลยทั้งสองกระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงเหลือโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี และ 16 ปี 8 เดือน ตามลำดับ รวมจำคุก 20 ปี 8 เดือน และคงเหลือโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 6 ปี และ 25 ปี ตามลำดับ รวมจำคุก 31 ปี

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสามและมาตรา 277 วรรคสาม แต่มีความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยปราศจากเหตุอันสมควรตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคแรก จำคุก 6 ปี ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก 3 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยที่ 1 เป็นคนกระทำชำเราคนแรก นายเตี้ยเป็นคนกระทำชำเราคนที่สองและ นายราชเป็นคนกระทำชำเราคนที่สาม โดยแต่ละคนไม่ได้ร่วมกันข่มขู่หรือใช้กำลัง เป็นการกระทำชำเราคนละครั้ง การกระทำของจำเลยที่ 2 มีลักษณะของการเป็น ตัวการร่วมกระทำชำเราผู้อื่นเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการร่วมกระทำผิดด้วยกันอันมี ลักษณะเป็นการโทรมหญิงซึ่งมีโทษหนักนั้น เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาว่า จำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดฐานเป็นตัวการกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมีใช้ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไม่ยินยอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม ฎีกาในข้อนี้ของจำเลยที่ 2 จึงถือ ไม่ได้ว่าเป็นการฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 และมาตรา 216 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ส่วนจำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาในทำนองขอให้รอ การลงโทษจำคุกนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษ ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง แต่คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 ลงโทษจำคุก 6 ปี และฐานร่วมกันกระทำชำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิง นั้นไม่ยินยอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 จำคุก 25 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่าจำเลยที่ 2 ไม่มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคสามและมาตรา 277 วรรคสาม แต่ความ ผิดฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยปราศจากเหตุอันสมควรตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 317 วรรคแรก จำคุก 3 ปี จึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค 6 แก้วรรคของความผิดในบทมาตรเดียวกัน ซึ่งมีระวางโทษต่างกันไม่มากนักและ เป็นการแก้ไขปรับบทให้ถูกต้องตามฟ้องโจทก์ ดังนั้นแม้ศาลอุทธรณ์ภาค 6 จะแก้

โทษด้วยก็เป็นการพิพากษาแก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ไว้โดยมิชอบ แต่เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะลงโทษจำเลยที่ 2 ให้เหมาะสมตามความผิดได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215, 225

อนึ่ง แม้หลังจากที่จำเลยที่ 1 กระทำความผิด ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 มาตรา 3 ยกเลิกความใน มาตรา 277 และให้ใช้ข้อความใหม่แทน แต่กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณแก่ จำเลยที่ 1 จึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยที่ 1 ไม่เป็น กรณีที่จะต้องแก้ไขคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองในส่วนนี้ แต่ความผิดฐานกระทำชำเรา เด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็ก หญิงและเด็กหญิงไม่ยินยอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม ที่ใช้ บังคับขณะจำเลยที่ 1 กระทำความผิด จะต้องมีส่วนร่วมกระทำชำเราเด็กหญิงอย่างน้อย สองคน โดยผลัดเปลี่ยนกันกระทำชำเราเด็กหญิงและโดยมีเจตนาร่วมกันในขณะ กระทำความผิด ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามทางนำสืบโจทก์จากคำเบิกความของ ผู้เสียหายที่ 2 และคำให้การในชั้นสอบสวนของผู้เสียหายที่ 2 ตามบันทึกคำให้การ เอกสารหมาย จ.5 และศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงโดยคู่ความไม่อุทธรณ์ฎีกาได้เพียง เป็นอย่างอื่นว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 พาผู้เสียหายที่ 2 ไปบ้านที่เกิดเหตุ ใน ระหว่างนั้นจำเลยที่ 1 กระทำชำเราผู้เสียหายที่ 2 จนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง ต่อมา จำเลยที่ 2 พานายเตี้ยมาบ้านที่เกิดเหตุและจำเลยที่ 2 พาจำเลยที่ 1 ออกไปจากบ้าน เกิดเหตุ หลังจากนั้นนายเตี้ยกระทำเราผู้เสียหายที่ 2 จนสำเร็จความใคร่ 1 ครั้ง และ ในเวลาใกล้เคียงต่อเนื่องกันนั้นยังมีนายราช ไม่ทราบนามสกุล กระทำชำเราผู้เสีย หายที่ 2 จนสำเร็จความใคร่อีก 1 ครั้ง นอกจากนี้ พยานหลักฐานโจทก์ก็ไม่ปรากฏว่า

จำเลยที่ 1 ได้ร่วมคบคิดหรือนัดแนะกับคนอื่นในการกระทำความผิดอย่างไร ดังนั้น การที่จำเลยที่ 1 กระทำซ้ำเราผู้เสียหายที่ 2 แล้วออกไปจากที่เกิดเหตุ จึงเป็นการ กระทำโดยลำพังเฉพาะตัว ไม่มีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดด้วยกันอันมี ลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้น อ้างและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 นอกจากนี้ที่ศาลล่างทั้งสองลดมาตราส่วนโทษแก่ จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ลงหนึ่งในสามแต่วางโทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานร่วมกันพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการอนาจาร จำคุกถึง 8 ปี ก่อนลดโทษให้นั้น เห็นสมควรแก้ไขเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่รูปคดี ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215, 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรกและมาตรา 317 วรรคสาม ประกอบมาตรา 83 เมื่อลดมาตราส่วนโทษ แก่จำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 ลงหนึ่งในสามแล้ว ให้วาง โทษจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานร่วมกันพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีเพื่อการ อนาจาร จำคุก 4 ปี และฐานกระทำซ้ำเราเด็กหญิงอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยา ของตน จำคุก 10 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 14 ปี ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่งคงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 7 ปี ส่วนจำเลยที่ 2 ให้วาง โทษจำคุก 3 ปี ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษ จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์ภาค 6

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ